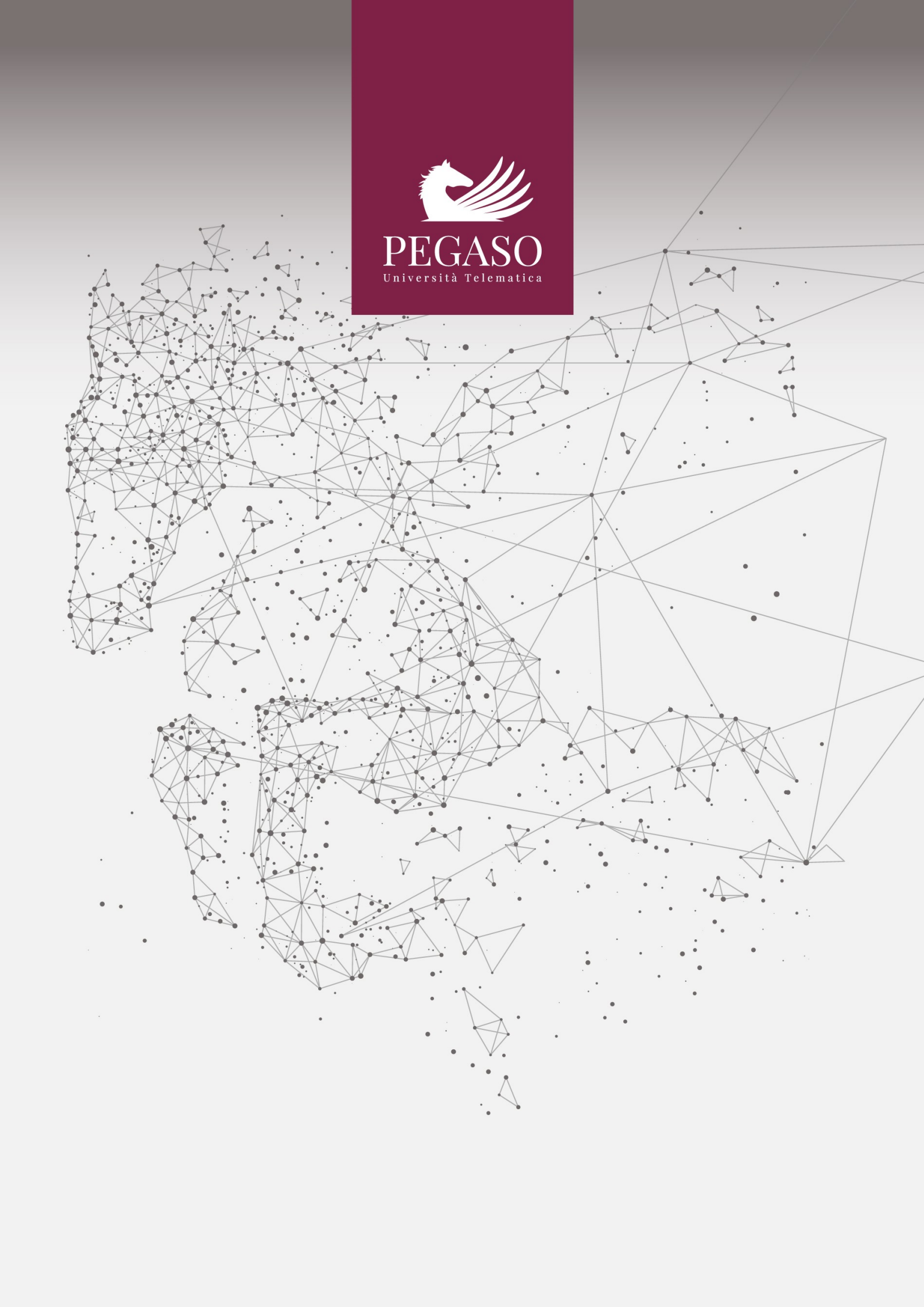

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Indice

1. LE UTILIZZAZIONI NELLA RETE 3
2. ULTERIORI PROFILI DI DIRITTO EURO-UNITARIO 6
3. LA RESPONSABILITÀ DEI CONTENT, ACCESS E SERVICE PROVIDER 8
BIBLIOGRAFIA 13

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

1. Le utilizzazioni nella rete

L'ingresso della società nell'era dell'accesso e la diffusione di internet, se da una parte hanno consentito l'elaborazione e lo scambio veloce di informazioni, dall'altra hanno causato il sorgere di diverse problematiche di tipo giuridico e legislativo.

In particolare, nella presente trattazione verranno affrontate le tematiche relative alla necessità del contemperamento degli interessi dei soggetti titolari di diritto d'autore con quelli dei soggetti titolari del diritto alla libertà di impresa, alla protezione dei dati personali e alla libertà di espressione; nonché le problematiche relative all'utilizzo del *linking* e al ruolo cruciale rivestito dagli ISP (c.d. *Internet Service Provider*).

Per quanto concerne la tutela del diritto d'autore in internet, il legislatore europeo è intervenuto con l'emanazione della **Direttiva 2001/29/CE** (nota con l'acronimo EUCD - *European Union Copyright Directive*), recepita nel nostro ordinamento mediante il **D.Lgs. n. 68/2003**, recante non solo norme di armonizzazione del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione, ma anche norme che impongono agli Stati Membri di adottare adeguate sanzioni contro la violazione dei diritti di proprietà intellettuale.

Tale intervento non è stato tuttavia risolutivo poiché risulta difficile, in concreto, individuare le misure più opportune da imporre agli intermediari che si siano resi responsabili di una violazione del diritto d'autore consentendo l'accesso degli utenti a materiale protetto, senza rischiare di comprimere eccessivamente la libertà di questi ultimi di fruire dei contenuti presenti sul *web*.

Per questa ragione, la Corte di Giustizia UE ha ribadito, nel corso degli anni, la necessità di effettuare un bilanciamento tra i predetti diritti.

Ciò significa che nel mondo di internet i principi proprietari del diritto d'autore non sono tutelati in maniera assoluta.

Si richiama sul punto la già citata **sentenza Promusicae** nella quale, per la prima volta, si afferma che gli Stati Membri, nella trasposizione delle direttive in materia di diritti di proprietà

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

intellettuale e tutela dei dati personali, devono interpretare le stesse in modo da garantire un giusto equilibrio tra i diritti fondamentali coinvolti.

Inoltre, viene richiesto ai giudici e alle autorità degli Stati Membri non solo di interpretare il diritto nazionale conformemente alle direttive in questione, ma anche di non adottare decisioni fondate su interpretazioni in contrasto con i diritti fondamentali o con gli altri principi del diritto comunitario, quale il principio di proporzionalità.

Sulla stessa scia si collocano altre due fondamentali decisioni, segnatamente la **sentenza Scarlet** e la **sentenza Netlog**, le quali hanno ritenuto lesiva della libertà d'impresa dei prestatori di servizi l'imposizione da parte del giudice nazionale di un sistema di filtraggio delle informazioni trasmesse o memorizzate, tale da consentire l'esclusione dei materiali protetti da *copyright*.

Sebbene le decisioni finora citate abbiano visto generalmente "soccombente" il diritto d'autore, nel panorama giurisprudenziale comunitario non sono mancate soluzioni di segno opposto.

Si segnala, in particolare, la sentenza della **Corte di Giustizia, Sez. IV, del 27 marzo 2014, causa C-314/12**, nella quale i giudici - pur non ribaltando i principi affermati nelle summenzionate decisioni - hanno ritenuto legittima la incisiva *injunction* adottata da un giudice nazionale nei confronti di un *internet provider*, ritenuta non confliggente con i diritti fondamentali dell'Unione Europea.

In specie, veniva imposto al *provider* di impedire ai propri utenti l'accesso su siti contenenti materiale protetto da *copyright* lasciando al primo ampia discrezionalità nella scelta delle misure ritenute più opportune allo scopo; e concedendogli, al contempo, di andare esente da ogni responsabilità qualora fosse stato in grado di dimostrare di aver adottato tutte le misure ragionevoli per evitare la violazione.

Inoltre, sempre nella medesima decisione vengono individuate le caratteristiche che le misure adottate in ottemperanza ad un'ingiunzione devono possedere nel rispetto di un giusto contemperamento dei diritti fondamentali a seconda dei casi considerati.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Si deve trattare, dunque, di provvedimenti che non privino inutilmente gli utenti dell'accesso al materiale lecito e che siano efficaci nell'impedire l'accesso a risorse illecite o, quantomeno, idonei a rendere particolarmente difficoltose le consultazioni non autorizzate.

E, del resto, anche l'idea per cui in tal modo il *provider* può andare esente da responsabilità – cioè dall'obbligo di risarcire i danni – contiene in sé una forma di bilanciamento fra opposte esigenze.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

2. Ulteriori profili di diritto euro-unitario

Ulteriori problematiche in tema di tutela di diritto d'autore in rete sono legate all'utilizzo del collegamento ipertestuale (c.d. *link*), che è lo strumento che consente agli utenti la navigazione da una pagina *web* all'altra.

Il collocamento su un sito di un collegamento ipertestuale che rinvia ad opere protette da *copyright* e non autorizzate dell'autore su un altro sito internet può in alcuni casi costituire una violazione.

La Direttiva 2001/29/CE dispone testualmente all'art. 3, paragrafo 1, che "*gli Stati membri riconoscono agli autori il diritto esclusivo di autorizzare o vietare qualsiasi comunicazione al pubblico, su filo o senza filo, delle loro opere, compresa la messa a disposizione del pubblico delle loro opere in maniera tale che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente*".

Considerata la rilevanza dell'attività di *linking* nello sfruttamento di contenuti altrui, la Corte di Giustizia è intervenuta mediante numerose pronunce, susseguitesi nel tempo, dirette a chiarire la portata della norma testé citata, di recente con la sentenza dell'8 marzo 2016 resa nel **caso GS Media**.

Tuttavia, preme evidenziare che già prima di tale intervento i giudici lussemburghesi si erano pronunciati sulla legittimità del *link* almeno in altre due occasioni, ossia nel **caso Svensson** e nel **caso Bestwater**, individuando le ipotesi in cui il collegamento ipertestuale deve essere considerato una comunicazione al pubblico, ai sensi dell'art. 3 della citata Direttiva.

Non ogni *link* che rimanda a contenuti tutelati da *copyright* richiede la previa autorizzazione del titolare del diritto.

Secondo quanto stabilito nei suddetti provvedimenti giudiziali, per ricadere nella nozione di "comunicazione al pubblico", di cui all'art. 3, della direttiva EUCD, un collegamento ipertestuale di questo tipo deve essere rivolto ad un pubblico nuovo, ossia ad una platea di utenti che non è stata presa in considerazione dal titolare del diritto d'autore al momento della concessione

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

dell'autorizzazione per la comunicazione iniziale al pubblico: salvo che, ovviamente, l'opera sia stata messa in rete senza il suo consenso.

Con la recente decisione del 2016 (**caso GS Media)**, la giurisprudenza comunitaria è poi intervenuta a circoscrivere ulteriormente l'ambito di applicazione dell'art. 3, prevedendo che il collocamento su un sito internet di un collegamento ipertestuale che rinvia ad opere dell'ingegno tutelate dal diritto d'autore, sebbene pubblicate senza l'autorizzazione del medesimo, non costituisce automaticamente una nuova comunicazione al pubblico qualora la persona che colloca tale *link* agisca senza fini di lucro e senza essere al corrente dell'illegittimità della pubblicazione di dette opere, ancora un volta nell'ottica del bilanciamento tra interessi coinvolti.

Diversamente, ci si troverebbe innanzi ad una eccessiva compressione della libertà di espressione e di informazione tutelata dall'art. 21 della Costituzione, atteso che non sempre è agevole capire, soprattutto per il privato, quando i *link* collocati sui siti rinviano a contenuti che non siano stati autorizzati.

Nel caso di specie, la Corte di Giustizia ha ritenuto che la GS Media non potesse non essere a conoscenza della pubblicazione su un proprio sito olandese di foto non autorizzate della sig.ra Dekker e dirette alla rivista Playboy, in quanto i titolari avevano provveduto a richiedere in più occasioni la rimozione dei contenuti.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

3. La responsabilità dei content, access e service provider

Anche gli *Internet Service Provider* possono giocare un ruolo importante nella violazione del diritto d'autore e, in generale, dei diritti di proprietà intellettuale.

A seconda del tipo di attività svolta gli ISP, si distinguono in:

1. ***Access provider***, cioè soggetti che garantiscono semplicemente la connessione alla rete telematica;
2. ***Service provider***, cioè soggetti che forniscono agli utenti i servizi legati alla rete;
3. ***Content provider***, cioè soggetti che mettono a disposizione del pubblico dei materiali di qualsiasi tipo, propri e di terzi.

Il legislatore comunitario, al fine di agevolare il commercio elettronico, ha introdotto agli artt. 12-15 della Direttiva 2001/31/CE una disciplina di favore nei confronti del *provider* "passivo", ossia di colui che svolge attività di ordine meramente tecnico e automatico.

Tanto è vero che all'art. 15 è stata prevista l'assenza di un obbligo generale di sorveglianza a carico degli ISP che svolgono le attività di cui agli artt. 12 ss.

In particolare, si tratta delle attività di "*mere conduit*" (trasmissione), "catching" (memorizzazione automatica, intermedia e temporanea) e "*hosting*" (memorizzazione non temporanea).

Ebbene, la citata Direttiva è stata recepita nel nostro ordinamento, quasi pedissequamente con il Decreto Legislativo n. 70 del 9 aprile 2003, che qui sarà esaminato nei suoi termini generali, prescindendo dalle specifiche applicazioni giurisprudenziali intervenute nell'ordinamento italiano, da esaminare in altra sede.

Per quanto concerne gli obblighi previsti a carico dei suddetti fornitori di servizi informatici, l'art. 17, comma 2, della disciplina italiana prevede che a prescindere dal tipo di attività posta in essere essi debbano «*a) informare senza indugio l'autorità giudiziaria o quella amministrativa avente funzioni di vigilanza, qualora sia a conoscenza di presunte attività o informazioni illecite*

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

riguardanti un suo destinatario del servizio della società di informazione; b) fornire senza indugio, a richiesta della autorità competenti, le informazioni in suo possesso che consentano l'identificazione del destinatario dei suoi servizi con cui ha accordi di memorizzazione di dati, al fine di individuare e pervenire attività illecite».

Di poi, al comma 3 del medesimo articolo e in tema di responsabilità del *provider* passivo, è previsto che «*il prestatore è civilmente responsabile del contenuto di tali servizi nel caso in cui, richiesto dall'autorità giudiziaria o amministrativa avente funzioni di vigilanza, non ha agito prontamente per impedire l'accesso a detto contenuto, ovvero, se, avendo avuto conoscenza del carattere illecito o pregiudizievole per un terzo del contenuto di un servizio al quale assicura l'accesso, non ha provveduto ad informare l'autorità competente*».

In altri termini, nel nostro ordinamento è stata introdotta una clausola generale non menzionata nel testo della Direttiva, la quale clausola porta a configurare la responsabilità del fornitore dei servizi informatici passivo, in due distinte ipotesi, segnatamente:

- nel caso in cui il prestatore non provveda nel più breve termine possibile ad impedire l'accesso ad alcuni contenuti su richiesta dell'autorità giudiziaria o amministrativa;
- nel caso in cui il prestatore abbia avuto conoscenza del carattere illecito di un servizio dallo stesso offerto e non abbia provveduto ad informare le autorità competenti.

Dunque, qualora sospetti che sia stato commesso un illecito grazie ai servizi forniti il *provider* dovrà semplicemente informare l'autorità giudiziaria, la quale è l'unica a poter valutare la necessità di rimuovere o inibire l'accesso al contenuto incriminato.

La *ratio* è sempre la medesima, ossia quella di operare un giusto bilanciamento fra i diritti coinvolti.

Infatti, se il fornitore dei servizi fosse costretto dal legislatore ad adottare un sistema di filtraggio delle informazioni, rischierebbe non solo di svolgere un ruolo di censore e, di conseguenza, di limitare la libera manifestazione del pensiero degli utenti, ma si esporrebbe altresì all'esercizio di numerose azioni di risarcimento danni qualora i contenuti rimossi si dovessero rivelare leciti.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Inoltre, verrebbe fortemente limitato il diritto alla libertà di impresa del prestatore del servizio stesso, il quale si troverebbe a dover sostenere dei costi ingenti per la creazione e gestione di un sistema di tal fatta.

Si rammenta al riguardo che la giurisprudenza comunitaria, nei summenzionati casi Scarlet e Netlog, ha escluso altresì che la stessa autorità giudiziaria possa proporre una simile soluzione.

È poi evidente come la disciplina normativa finora illustrata non trovi applicazione nei confronti del *content provider*, ossia di colui che rilascia in rete contenuti propri o di terzi, il quale sarà responsabile al pari degli altri soggetti dell'ordinamento per gli eventuali illeciti commessi.

Nel caso di contenuti rilasciati da terzi si fa riferimento al concetto di responsabilità per fatto altrui.

In particolare, per quanto concerne la tutela del diritto d'autore nei confronti dei *provider*, già la Direttiva 2001/29/CE aveva attribuito la facoltà al titolare di un'opera dell'ingegno o di un diritto connesso di chiedere un provvedimento inibitorio nei confronti degli intermediari i cui servizi erano stati sfruttati da terzi a fini illeciti, con lesione dei diritti di cui si tratta.

Di recente, il Tribunale di Milano, con ordinanza del 27 luglio 2016 ha ribadito che alla luce della Direttiva 2001/29/CE le misure adottate dagli Stati Membri devono essere idonee non solo a far cessare le violazioni del diritto d'autore, ma anche a prevenirle.

Al contempo, nel medesimo provvedimento giudiziale, rispetto alle misure che devono essere adottate dai *provider* si precisa che esse devono essere dirette all'eliminazione delle violazioni del diritto d'autore e dei diritti connessi, senza pregiudizio per i diritti degli utenti di internet.

Dunque, non sono poche le problematiche che ruotano intorno al diritto d'autore nella rete e allo stesso diritto della rete.

In proposito, si segnala che il 7 luglio 2016 è stata approvata in sede legislativa, in prima lettura, la proposta di legge A.C. 2520, la quale riguarda disposizioni in materia di fornitura dei servizi della rete internet, utile ad interpretare le norme sopra richiamate.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Tale proposta prevede intanto il divieto di configurare - nell'offerta commerciale al pubblico e nella documentazione contrattuale ed informativa dei fornitori di reti e servizi di comunicazione elettronica – un "*accesso ad Internet*" o un "*servizio internet*" come accesso o servizio di connettività che limitino la possibilità di fruizione da parte dell'utente a una porzione e/o sottoinsieme di servizi offerti sulla rete internet.

Sono inoltre state introdotte alcune disposizioni concernenti le limitazioni all'accesso: il principio che le informa è quello di evitare che i fornitori ostacolino l'accesso ad applicazioni e servizi internet, ovvero lo rallentino rispetto alla velocità alla quale sarebbe fornito a un utente nella stessa area avente la medesima capacità di banda e con accesso illimitato alla rete.

Sono peraltro previste alcune eccezioni.

I casi in cui un rallentamento o una limitazione è ammessa sono infatti i seguenti:

a) *prevenire o mitigare gli effetti della congestione del traffico nella rete internet, a condizione che tipologie differenti di traffico siano trattate con le medesime modalità;*
b) *preservare l'integrità e la sicurezza della rete internet nonché del servizio del fornitore di reti o servizi di comunicazione elettronica in oggetto o del terminale dell'utente finale;*
c) *limitare la trasmissione a un utente finale di comunicazioni non richieste, previo consenso dello stesso utente;*
d) *dare attuazione a specifici, cogenti e inderogabili provvedimenti legislativi o giurisdizionali.*

È previsto inoltre il riconoscimento di un servizio internet di base, definito accesso "*best effort*" alla rete *internet*, che rappresenta la modalità di utilizzo della rete internet in cui non vi è garanzia che i pacchetti dati siano effettivamente consegnati a destinazione, non essendo presenti specifiche tecniche e livelli di servizio, in quanto la qualità del servizio è determinata dal carico di rete.

Secondo tale proposta l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha il ruolo di stabile appositi *standard* minimi di qualità del servizio, aggiornati con cadenza almeno annuale, che devono essere rispettati e adeguatamente pubblicizzati dai fornitori di reti o servizi di comunicazione elettronica.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

È stabilita inoltre una procedura da seguire ove il comportamento di utenti della rete possa arrecare pregiudizio ad altri utenti, ai fornitori del servizio ovvero alla rete in sé considerata, nella sua interezza.

Si riconosce anche il diritto di disinstallare *software* e di rimuovere contenuti non di interesse dai propri dispositivi, salvo che tali *software* siano previsti come obbligatori da norme imperative o siano essenziali per l'operatività o la sicurezza del dispositivo stesso, delle reti pubbliche di comunicazioni alle quali si connette o dei dati gestiti dal dispositivo.

Quanto alle società che forniscono i servizi è previsto l'obbligo, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, di pubblicare nella sezione relativa alla trasparenza dei prezzi del proprio sito internet le offerte commerciali praticate, specificando quali garantiscano un accesso alla rete internet e quali integrino le misure di "prioritarizzazione" delle classi di traffico nel proprio segmento di rete di accesso per soddisfare specifiche esigenze della clientela affari e residenziale.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Bibliografia

- F. Pizzetti, *Il caso del diritto d'autore*, Giapichelli, Torino, 2013.

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).